

次の【文章】のアからオまでの（ ）内には後記【語句群】のaからgまでの語句のいずれか、甲及び乙の《 》内には文章中に記載した①から④までの事情のいずれかが入る。エ及びオに入る適切な語句、甲及び乙に入る適切な事情の組合せとして正しいものは、後記1から8までのうちどれか。なお、アからオまでの（ ）内には、それぞれ異なる語句が入る。

【文 章】

(ア)は、伝聞証拠に当たるが、刑事訴訟法は、供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠とすることができると定めている。この場合、①供述内容が細かな事実にあふことが多いため、記憶に基づく口頭報告よりも書面による記録と報告の方が正確性を期し得ること、②専門的学識に基づく供述として一般的に信用性が高いこと、③宣誓の上行われること、④検察官及び弁護人に立会権が認められていることにより公正さが担保されていること、などの事情が考慮されたものといえる。

最高裁判所は、(イ)や(ウ)も、同じ要件の下に証拠能力が認められるとしている。(イ)の場合、(ア)について指摘した《甲》と《乙》の事情は当てはまらず、両者の間には(エ)の点で差異があることは否定できないが、刑事訴訟法の明文で(オ)も(ア)と同じ要件の下に証拠能力が認められていることを考慮すれば、最高裁判所の結論も不当とはいえない。しかし、(ウ)の場合には、(ア)と同じ要件の下に証拠能力が認められてよい理由は、主として(ア)について指摘した②の事情が共通することに求めるしかなく、最高裁判所の結論には批判もある。真正に作成されたものであることを供述するとは、内容の正確性についても実質的に反対尋問を受けることと解されていることが、このように緩やかな解釈の背景といえる。

【語句群】

- a. 私人が依頼した医師作成の診断書
- b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書
- c. 捜査機関が囑託した鑑定受託者作成の鑑定書
- d. 捜査機関の検証の結果を記載した調書
- e. 裁判所の検証の結果を記載した調書
- f. 信用性の情勢的保障
- g. 必要性

1. エーf オーa 甲ー① 乙ー②
2. エーf オーa 甲ー③ 乙ー④
3. エーf オーd 甲ー② 乙ー③
4. エーf オーd 甲ー③ 乙ー④
5. エーf オーc 甲ー① 乙ー④
6. エーf オーe 甲ー② 乙ー③
7. エーg オーc 甲ー② 乙ー④
8. エーg オーe 甲ー① 乙ー③

() には順に、ア＝「b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書」、イ＝「c. 捜査機関が嘱託した鑑定受託者作成の鑑定書」、ウ＝「a. 私人が依頼した医師作成の診断書」、エ＝「f. 信用性の情況的保障」、オ＝「d. 捜査機関の検証の結果を記載した調書」と入る。《 》には、甲＝③、乙＝④と入る。したがって、正解は肢4となる。

完成全文

(ア b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書)は、伝聞証拠に当たるが、刑事訴訟法は、供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠とすることができると定めている。この場合、①供述内容が細かな事実及びことが多いため、記憶に基づく口頭報告よりも書面による記録と報告の方が正確性を期し得ること、②専門的学識に基づく供述として一般的に信用性が高いこと、③宣誓の上行われること、④検察官及び弁護人に立会権が認められていることにより公正さが担保されていること、などの事情が考慮されたものといえる。

最高裁判所は、(イ c. 捜査機関が嘱託した鑑定受託者作成の鑑定書)や(ウ a. 私人が依頼した医師作成の診断書)も、同じ要件の下に証拠能力が認められるとしている。(イ c. 捜査機関が嘱託した鑑定受託者作成の鑑定書)の場合、(ア b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書)について指摘した《甲③》と《乙④》の事情は当てはまらず、両者の間には(エ f. 信用性の情況的保障)の点で差異があることは否定できないが、刑事訴訟法の明文で(オ d. 捜査機関の検証の結果を記載した調書)も(ア b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書)と同じ要件の下に証拠能力が認められていることを考慮すれば、最高裁判所の結論も不当とはいえない。しかし、(ウ a. 私人が依頼した医師作成の診断書)の場合には、(ア b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書)と同じ要件の下に証拠能力が認められてよい理由は、主として(ア b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書)について指摘した②の事情が共通することに求めるしかなく、最高裁判所の結論には批判もある。真正に作成されたものであることを供述するとは、内容の正確性についても実質的に反対尋問を受けることと解されていることが、このように緩やかな解釈の背景といえる。

ア b

まず、アには問題文より伝聞証拠にあたるものが入ることが分かる。そして、問題文は「刑事訴訟法は、供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠とすることができると定めている」としているところ、刑事訴訟法上そのような条件のもと証拠能力が認められているのは、「b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書」

(321条4項)と、「d. 捜査機関の検証の結果を記載した書面」(同条3項)であるので、アにはbとdのいずれかが入る。そして、法がアについて証拠能力を認めた趣旨が①から④まで述べられているが、このうち、「②専門的学識に基づく供述として一般的に信用性が高いこと」は、鑑定書にあてはまる特徴であるといえる。したがって、アにはbが入る。

オ d

次に、イ、ウも証拠能力が認められるとしているので、a、c、d、eのいずれかが入る。しかしこの時点で確定することは難しいので、保留する。イについては、問題文より、裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書に、伝聞例外として証拠能力が認められるとする理由である①から④のうちの2つがあてはまらないこと、さらに裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書とイの伝聞証拠では、エの点で差異があることが分かる。また、問題文は「刑事訴訟法の明文で(オ)も(ア)と

同じ要件の下に証拠能力が認められていることを考慮すれば、最高裁判所の結論も不当とはいえない。」としているので、オの伝聞証拠との比較により、イにも証拠能力を認めることが最高裁の解釈にも合致すると述べているものといえる。そして、オには裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書と同様の要件の下で明文上、証拠能力が認められる伝聞証拠が入るが、それは「d. 捜査機関の検証の結果を記載した書面」であり、オにはdが入る。

エ f

更に、エにつき、語句群の中で差異の内容として考えられるのは、「f. 信用性の情況的保障」と「g. 必要性」である。語句群に挙げられている伝聞証拠はいずれも検証調書や鑑定書（ウで述べるように、医師の診断書も鑑定結果を記した書面としての性質を有する）としての性質を有するものであり、内容の複雑性という観点からはいずれも書面により提出する必要性が認められるという点では異ならない。したがって、エには「g. 必要性」ではなく、「f. 信用性の情況的保障」が入る。

イ c

そして、エに「f. 信用性の情況的保障」が入るとすると、アの「b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書」とイの伝聞証拠は、信用性の情況的保障において差異が生じることになる。語句群の中で、アの「b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書」と信用性の情況的保障において差異が生じ得るのは、「a. 私人が依頼した医師作成の診断書」と、「c. 捜査機関が囑託した鑑定受託者作成の鑑定書」である。最高裁判所がイに証拠能力を認める理由として、アの「b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書」とオの「d. 捜査機関の検証の結果を記載した書面」が同じ要件の下に証拠能力が認められていることを述べていることからすれば、作成主体が、裁判所又は裁判官であるか捜査機関であるかに着目していることが分かる。また、最判昭28.10.15（百選A39事件）は、「捜査機関の囑託に基く鑑定書（刑訴223条）には、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する刑訴321条4項を準用すべき」と判示している。したがって、イには「c. 捜査機関が囑託した鑑定受託者作成の鑑定書」が入る。

甲 ③

乙 ④

また、イの「c. 捜査機関が囑託した鑑定受託者作成の鑑定書」においては、アの「b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書」につき法が伝聞例外とした根拠である宣誓による信用性の情況的保障（166条参照）と検察官及び弁護人の立会権（170条参照）が認められないという差異がある。したがって、甲、乙には、それぞれ③、④が入る。

ウ a

ウについてであるが、語句群で残った伝聞証拠は、「a. 私人が依頼した医師作成の診断書」と「e. 裁判所の検証の結果を記載した調書」である。問題文は、ウについてアと同じ要件の下に証拠能力を認めてよいとしているが、「e. 裁判所の検証の結果を記載した調書」については、より緩やかな要件の下で証拠能力が認められている（321条2項）。したがって、ウには「e. 裁判所の検証の結果を記載した調書」ではなく「a. 私人が依頼した医師作成の診断書」が入る。

なお、私人が依頼した医師作成の診断書について最判昭32.7.25は、「医師の作成した診断書には正規の鑑定人の作成した書面に関する刑訴法321条第4項が準用されるから診断書の作成者が公判期日……において証人として尋問を受けてその真正に作成されたものであることを供述したときは証拠能力をもつようになる。」とした原審（福岡高判昭31.10.30）を正当と判示している。このことから、ウにはaが入ることを導くことができる。

